

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0072310-58.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **GABRIEL MATOS DE PAULA**

Juiz de Direito: Dr. **Júlio Alexandre Felix de Faria.****Vistos.**

GABRIEL MATOS DE PAULA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções cominadas no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, em 16 de agosto de 2017, por volta de 11h35min, na Rua Arca da Aliança, nº 10, Lajeado, nesta cidade e comarca, estaria trazendo consigo e expondo à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sete invólucros contendo cocaína na forma de crack, com peso de 6,8g (seis gramas e oito decigramas), cinquenta e nove porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 24,1g (vinte e quatro gramas e um decigrama), dezessete papérolas de tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 41,5g (quarenta e um gramas e cinco decigramas), e um vidro contendo “lança-perfume”, os quais se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da denúncia de fls. 01/02.

Após o oferecimento da denúncia, houve a apresentação de defesa prévia (fls. 147/149). A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2017 (fls. 156/157). O réu foi citado pessoalmente e, durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, após, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 161/162 e 176/179). Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante referente à confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo previsto em lei, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a possibilidade de o réu apelar em liberdade (fls. 180/182).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, verifico a inexistência de quaisquer nulidades, bem como não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo que passo à apreciação do mérito.

A materialidade delitiva se encontra estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 31/34, no laudo de constatação de entorpecentes de fls. 35/37 e nos laudos de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

exame químico-toxicológicos de fls. 134/139.

Também não há dúvidas no tocante à autoria.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado admitiu a veracidade da imputação formulada na denúncia, tendo dito que estava “vendendo drogas por motivo de necessidade”.

A confissão do acusado encontrou respaldo nos depoimentos dos policiais militares André Luiz dos Santos Rossi e Leonardo da Silva Carneiro, ouvidos em juízo a fls. 162 e 176, os quais informaram, com riqueza de detalhes, as circunstâncias em que, na data dos fatos, houve a abordagem do acusado e a apreensão das drogas, de maneira a corroborar totalmente a narrativa constante da denúncia.

Sobre o valor da confissão em juízo, tem-se o ensinamento de Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha (in “Da Prova no Processo Penal”, página 15, 5ª edição, 1999, editora Saraiva):

“A confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.

(...) Em resumo: Havendo confissão judicial, que só se pode presumir livremente feita, desde que não demonstrada a sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus passa a ser do confitente, só ela já autoriza e serve como alicerce para uma decisão condenatória.”

Da mesma forma, não há motivos para não se atribuir credibilidade aos depoimentos dos policiais militares ouvidos nos autos, haja vista que são coerentes e harmônicos entre si, bem como porque não se demonstrou que eles poderiam ter qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao acusado.

Ademais, a jurisprudência tem admitido que, por se tratar de atos emanados de agentes da Administração Pública, os depoimentos prestados por policiais, sejam civis ou militares, possuem presunção *juris tantum* de veracidade e legitimidade, afastável somente mediante inequívoca demonstração em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito:

“Sabe-se que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do apelante, que os depoimentos dos policiais estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria, mormente neste caso em que as suas palavras foram confirmadas pelas provas amealhadas em contraditório.”
(Apelação nº 0019309-66.2011.8.26.0278 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de agosto de 2013 – votação unânime).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“Necessário ressaltar a importância das falas destes profissionais que, escolhidos pelo Estado para desempenhar nobre função, possuem fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade, mesmo porque não restou provada qualquer intenção dos servidores em, de alguma forma, prejudicar o réu.

Assim, não se pode desmerecer o depoimento de agentes policiais apenas por sua condição de agente da lei, consoante lição do mestre ARY BELFORT, que afirma:

'A tese da insuficiência testemunhal quando emane de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão.' (RJTJESP 136/477).

Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções.

Em sendo assim, tal depoimento reveste-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório; não havendo provas de que teriam o único intuito de incriminar pessoa inocente.

Ademais, como afastaríamos tais palavras, se na esmagadora maioria das prisões por crime de tráfico as únicas testemunhas são os próprios policiais condutores? Seria um equívoco jurídico, com implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a absolver indistintamente réus em casos como o presente, em que a fala dos policiais acaba sendo determinante para a condenação.” (Apelação nº 0006119-11.2012.8.26.0372 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Edison Brandão – julgado em 22 de abril de 2014 – votação unânime).

Não faria sentido algum que os agentes públicos ingressassem, após prestarem compromisso de bem e fielmente desenvolverem suas nobres funções, na Polícia Militar e que, depois, no momento de comparecerem em juízo para prestarem depoimento, o Estado negasse crédito às suas informações, mormente quando elas se referem a atos presenciados por ocasião do cumprimento de seus deveres funcionais.

Nesse sentido:

“(…) falando-se em policiais, civis ou militares, há de se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que sejam, prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, 'a priori', dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados de pessoas revestidas de tal qualidade.” (Apelação nº 0004092-12.2012.8.26.0451 – 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Airton Vieira – julgado em 14 de abril de 2014 – votação unânime).

Na jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Validade do depoimento testemunhal de agentes policiais. – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (STF – HC 73.518/SP – 1ª Turma – Rel. Min. Celso de Mello – DJ 18.10.1996 – p. 39.846).

Cumprе consignar que a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser imprescindível, para a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, o testemunho de pessoas estranhas aos quadros policiais, entendimento esse que foi brilhantemente sustentado no seguinte julgado:

“(…) segundo entendimento jurisprudencial majoritário, o depoimento de um policial tem o mesmo valor que o de um civil, ambos respondendo pelo falso testemunho que possam prestar, pelo que só deve ser rejeitado quando seguramente infirmado por outro elemento da prova, o que certamente não ocorre no presente feito. Assim, o depoimento prestado por policiais tem validade, havendo presunção 'juris tantum' de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (RJTJESP, ed. LEX, 136/476 e 495, 135/493, 129/501, 125/563, 122/489, 115/253, 107/457, 97/467, 95/468, 93/400, 90/496, 81/391 e 70/371).

(…)

Ademais, a conduta dos policiais, no exercício de suas funções, tem presunção de veracidade, exatamente em função do cargo público que eles ocupam, de modo que caberia à douda defesa demonstrar que os policiais agiram de modo tendencioso com a intenção a prejudicar os acusados, situação que não restou demonstrada nos autos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Acrescente-se que, a falta de indicação de testemunhas estranhas aos quadros policiais não pode ser guindada como causa de suspeição dos depoimentos de seus agentes ou como fator impeditivo à procedência do pedido condenatório. Como se sabe, encontrar cidadãos que se prestem a testemunhar contra pessoas envolvidas com o crime, ficando expostos a prováveis e temíveis represálias, não é tarefa simples e rotineira. Mormente, diante dos graves problemas enfrentados pela sociedade diuturnamente.” (Apelação nº 0003705-95.2011.8.26.0268 – 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Borges Pereira – julgado em 11 de março de 2014 – votação unânime).

Não há dúvidas, ainda, acerca da destinação dos entorpecentes apreendidos, haja vista que a confissão do acusado e as circunstâncias da prisão, aliadas à quantidade, à natureza e à diversidade dos entorpecentes apreendidos, os quais já se encontravam embalados individualmente e, portanto, já prontos para o fornecimento a terceiros, comprovam, de maneira inequívoca, a finalidade de entrega a terceiros.

Consigne-se que, para a caracterização da traficância, a jurisprudência é remansosa acerca da desnecessidade de identificação de qualquer suposto cliente para o qual a droga se destinaria, também não sendo necessário que o agente seja observado ou abordado enquanto praticava atos efetivos de mercancia.

Por estarem comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitivas, bem como o fato de que as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos eram destinadas à entrega a terceiros, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida de rigor, pelo que passo à aplicação da pena.

Passo à aplicação da pena.

Atendendo às disposições constantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, bem como ao critério trifásico previsto no artigo 68, ambos do Código Penal, verifico que o acusado, à data dos fatos, era primário e possuía bons antecedentes, não havendo informações nos autos acerca de sua personalidade ou de sua conduta social; por seu turno, a quantidade de entorpecentes que foi apreendida, não obstante sua diversidade, não se presta a justificar a majoração da pena na primeira fase de sua dosimetria. Por tais motivos, considero as circunstâncias judiciais como inerentes ao delito praticado e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase da aplicação da pena, porquanto a confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, verifico que o réu é primário, possuidor de bons antecedentes e que não há nos autos quaisquer indicativos de que ele se dedicaria a atividades delitivas ou integraria qualquer organização criminosa, pelo que é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, de um sexto a dois terços.

É fundamental observar que o legislador não estipulou os critérios para a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diminuição exigida pelo dispositivo legal em tela, apenas mencionando que o Magistrado deve reduzir a pena de um sexto a dois terços.

Ante a omissão legislativa, o julgador deve se pautar pelos elementos do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, de forma que a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes devem ser levadas em consideração para se chegar ao *quantum* referente à diminuição da pena.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas.” (HC 229.694/MG, 6ª Turma, Rel. Rogerio Schietti Cruz, DJ de 17 de dezembro de 2013).

No caso dos autos, ante a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes que foram apreendidas em poder do réu, ele não faz jus à máxima diminuição de pena prevista em lei, pelo que considero adequado fixar o *quantum* da redução em metade, tornando a pena definitiva em **02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA**, por não haver outras circunstâncias a considerar.

Acerca da redução de pena em apenas metade, em razão da diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas:

“(…) considerando a grande quantidade e diversidade da droga, adequada a aplicação do redutor na fração de metade (1/2), em observância às regras norteadoras previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (…)” (Apelação nº 0049085-48.2013.8.26.0050 – 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Newton Neves – julgado em 19 de agosto de 2014 – votação unânime).

“(…) reconhecido o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, houve a diminuição da pena imposta em ½.

Neste ponto, busca a defesa maior redução, ao patamar mínimo, porém sem sorte.

Não se pode perder de vista que (…) foi surpreendido por trazer consigo 25 pedras de “crack”, 13 pinos de cocaína e 24 porções de maconha, entorpecentes diversos, sendo o primeiro de natureza extremamente deletéria, o que denota a necessidade de uma maior reprovabilidade à sua conduta, impossibilitando a **redução máxima.**” (Apelação nº 0007838-78.2012.8.26.0323 – 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Salles Abreu – julgado em 20 de agosto de 2014 – votação unânime).

Importante observar que, conforme a Súmula nº 512, de recente aprovação pelo Superior Tribunal de Justiça, *“A aplicação da causa de diminuição de pena*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime **FECHADO**, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal e no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, vez que, não obstante a pena ora fixada não seja superior a oito anos, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, ante a elevada culpabilidade de agentes que cometem tráfico ilícito de entorpecentes, e se encontra em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (artigo 5º, inciso XLIII). Consigne-se que não pode ser desconsiderada a gravidade específica e concreta do caso em análise, por força da diversidade de drogas que foi apreendida em poder do réu, a demonstrar sua maior culpabilidade, de forma a também justificar a imposição do regime inicial fechado.

Sobre o regime inicial fechado para condenados por tráfico ilícito de entorpecentes:

“(...) a traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade.

Por isso, o legislador Constitucional estabeleceu tratamento severo para o crime de tráfico (artigo 5º, inciso XLIII, LI e artigo 243, parágrafo único, ambos da CF). No mesmo sentido se direcionou o legislador infraconstitucional, que equiparou o tráfico a crime hediondo, subordinando os autores de delitos desse gênero à previsões específicas e mais rigorosas fixadas pela Lei nº 8.072/90.

Destarte, mostra-se incompatível com o sistema a fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco sursis, uma vez que o objetivo da Lei foi desestimular a comercialização de drogas, impondo sanções rígidas àquele que dissemina o vício.

Assim, atentando-se à gravidade do crime e da periculosidade da agente, que portava grande quantidade de drogas variadas e extremamente nocivas, percebe-se que a fixação de regime diverso do fechado para o cumprimento da pena ou substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, bem como concessão de sursis, não são indicadas para sua reeducação, bem como repressão do delito, sendo recomendável a aplicação do regime prisional inicialmente fechado para o desconto corporal, nos moldes constantes da decisão combatida.” (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo vigente no dia do fato, corrigido em sede de execução, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por não haver provas nos autos de que o réu possua boa situação financeira.

Não obstante a quantidade da pena ora fixada, é incabível o *sursis*, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme entendimento sustentado nos seguintes julgados:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

“No que diz respeito ao pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos formulado pela defesa, apesar da recente Resolução nº 5 editada pelo Senado Federal, através da qual ficou suspensa a expressão '*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*' presente no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal benefício não seria possível no presente diante das circunstâncias do caso concreto, vez que os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos. O que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, '*os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente*'.

Assim, embora o crime tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal).

Os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a não observância de um dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena é inadmissível.

Este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

'Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou' (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

E também o adotado por este Colendo Tribunal:

(...)

'impossível a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, ou mesmo a concessão do sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela uma gravidade peculiar, ferindo o equilíbrio social e desestabilizando a sociedade, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos crimes hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a concessão do sursis.' (TJSP. Apelação 0023644-33.2010.8.26.0224. Relator: Luís Carlos de Souza Lourenço. 5ª Câmara de Direito Criminal. DJ 26/01/2012).

(...)

O mesmo raciocínio se aplica no tocante ao pedido de suspensão condicional da pena, visto que o artigo 77, do Código Penal, em seu inciso II, estabelece igual condição para a concessão do benefício.

Por fim, inviável que o regime prisional inicial seja outro diverso do fechado, em razão da existência de expressa proibição legal (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90). Vedação esta que não se mostra maculada de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inconstitucionalidade, posto que e a Carta Magna preconizou o tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal).

Sendo que tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.

Além disso, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.

Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.” (Apelação nº 0002655-14.2011.8.26.0210 – 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Aguinaldo de Freitas Filho – julgado em 28 de março de 2014 – votação unânime).

“A despeito do volume das penas impostas (superior a 4 anos) não permitir a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, fica uma observação: a substituição é incabível por evidente incompatibilidade do benefício com a conduta de quem trafica, disseminando o mal na sociedade, com a nota de que a lei estabelece o regime inicial fechado para casos tais. A conduta examinada, evidentemente, não se encontra entre aquelas em que o legislador pretendeu favorecer o réu com a benesse. Substituição, no caso dos autos, implicaria na mais clara e odiosa impunidade, em desprestígio para o Poder Judiciário e risco concreto para a sociedade, que se vê refém dos efeitos nefastos da ação delitiva. A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é tão perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família, para o exercício do comércio ilícito, que fica até mesmo difícil imaginar uma pena substitutiva para ser aplicada, se fosse caso. Ademais, condutas como a do acusado disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros crimes graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático. Por fim, importante ressaltar que a conduta do peticionário também não se amolda aos parâmetros estabelecidos no artigo 44, do Código Penal.

O regime para o tráfico de entorpecentes, com o advento da Lei nº 11.464/2007, deve ser o inicial fechado. Não se vislumbra, ademais, em face dos motivos já expostos, regime outro capaz de atender ao binômio reprovação-prevenção.” (Revisão Criminal nº 0008791-07.2013.8.26.0000 – 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Relator Pinheiro Franco – julgado em 27 de março de 2014 – votação unânime).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA, para o fim de CONDENAR o acusado GABRIEL MATOS DE PAULA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, no regime inicial FECHADO, vedadas quaisquer substituições previstas em lei, bem como à pena pecuniária de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, com a diária no mínimo legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, caput, combinado



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

com o parágrafo 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, o que demonstra que subsistem os requisitos da prisão preventiva, máxime agora, com sentença penal condenatória, não havendo, pois, quaisquer motivos para a concessão de liberdade provisória em seu favor, pelo que não poderá apelar em liberdade.

Nesse sentido:

“É pacífico na jurisprudência que o direito de recorrer da sentença penal condenatória em liberdade não se aplica ao réu já preso em decorrência de flagrante ou de prisão preventiva, que assim permaneceu durante todo o curso da instrução criminal, ou pelo menos grande parte dele.

Confira-se, a respeito, o posicionamento desta C. Câmara, ao decidir questões semelhantes:

'Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada.' (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

'HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Regime inicial fechado - Fixado de acordo com a legislação vigente - Apelo em liberdade vedado - Réu que permaneceu preso durante o processo - Não ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência - Ordem denegada.' (HC nº 0181659-59.2011.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Marques e Silva, j. 12/04/2012, V.U.).

O C. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a respeito, afirmando: 'A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.' (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Deveras, não haveria qualquer lógica em manter o acusado preso durante a instrução e, sobrevindo condenação, ainda que não transitada em julgado, soltá-lo para aguardar o julgamento da apelação interposta. Ao contrário, a prolação de sentença condenatória reforça e ratifica o cabimento da prisão. Assim, não se caracteriza, aqui, medida desproporcional que revele o alegado constrangimento do paciente.” (Habeas Corpus nº 2055783-89.2013.8.26.0000 – 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator De Paula Santos – julgado em 27 de março de 2014 – votação unânime).

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que nesta oportunidade lhe concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

Por se tratar de proveitos auferidos com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, determino o perdimento dos valores apreendidos nos presentes autos, nos termos do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

artigo 63 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/2006.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**